

1500085-54.2022.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016.

TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira-SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500085-54.2022.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500085-54.2022.8.26.0546

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026144/2022 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 22706091 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 231/22/309 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 2026144 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DANIEL ROBERTO DA SILVA ZERBINATTI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de DANIEL ROBERTO DA SILVA ZERBINATTI, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo o 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, Lei de Drogas, por duas vezes, e 12, da Lei n. 10.826/2003, Estatuto do Desarmamento, tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, afirmando que no dia 28 de janeiro de 2022, na Rua João Pulz, n. 150, Jardim Santa Izabel, CEP 13160-000, nesta cidade e Comarca de Artur Nogueira/SP, guardava, para fins de tráfico de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) tijolo de maconha, 04 (quatro) pedras de crack, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) porção de maconha petrificada e 02 (duas) porções de cocaína, pesando, ao todo, 661,1g (seiscentos e

sessenta e um gramas e um decigrama).

Consta, também, dos incluídos Autos de Prisão em Flagrante que, no dia 28 de janeiro de 2022, na Rua Dr. Moacir do Amaral, n. 51, fundos, Bairro Bela Vista, em Cosmópolis/SP, o denunciado guardava, para fins de tráfico de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) tablete de maconha e 06 (seis) porções de cocaína, pesando, ao todo, 47g (quarenta e sete gramas).

Consta, por fim, que o denunciado, no dia 28 de janeiro de 2022, na Rua Dr. Moacir do Amaral, n. 51, Bairro Bela Vista, em Cosmópolis/SP, possuía munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, a Polícia Civil, acompanhada da Guarda Municipal, buscando investigar uma ocorrência de roubo chegou ao endereço em que o denunciado costumava permanecer na cidade de Artur Nogueira e teve a entrada franqueada por TAINA CRISTINA RAMOS DA SILVA. Eis que a força policial pôde constatar que o acusado guardava, no fundo do imóvel, 01 (um) tijolo de maconha, 04 (quatro) pedras de crack, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) porção de maconha petrificada e 02 (duas) porções de cocaína, pesando, respectivamente, 327g (trezentos e vinte e sete gramas), 15g (quinze gramas), 128g (cento e vinte e oito gramas), 17,9g (dezessete gramas e nove decigramas) e 173,2 (cento e setenta e três gramas e dois decigramas). No imóvel havia ainda 02 (duas) balanças de precisão, 02 (duas) facas com resquícios de entorpecentes, 01 (um) caderno com anotações típicas do tráfico ilícito de entorpecentes, 133 (cento e trinta e três) pinos vazios para o armazenamento de drogas e 01 (um) aparelho celular Samsung cor azul.

No mais, o acusado possuía também um cartucho íntegro de uso permitido e calibre .357 Magnum.

Em seguida, TAINA CRISTINA informou o endereço da residência real do acusado, tendo a Polícia Civil e a Guarda Municipal seguido para o local. Nele, o tio do denunciado permitiu a entrada dos investigadores e da Guarda Municipal. Nos fundos do imóvel, local habitado pelo denunciado, foram encontrados 01 (um) tablete de maconha e 06 (seis) porções de cocaína, pesando, respectivamente, 5g (cinco gramas) e 42g (quarenta e duas gramas). No local eram mantidos, por igual, um aparelho celular Motorola cor cinza e um aparelho celular Motorola de cor rosa de propriedade do acusado, além de dois aparelhos celulares pertencentes a HIGOR, seu amigo.

Além disso, foram encontrados R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em dinheiro, 01 (um) rolo de fita adesiva, embalagens plásticas, 01 (um) coador, 01 (uma) tesoura com resquícios de entorpecentes e 01 (um) boné. O denunciado e seu amigo HIGOR estavam cortando o cabelo na mesma rua, motivo pelo qual a Polícia Civil e a Guarda Municipal os abordaram no estabelecimento comercial, tendo logrado encontrar com o acusado, dentro de sua carteira, R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

O artigo 12 da Lei 10.826/03 assim descreve o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido:

"Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua

residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas à posse de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) praticar tal conduta.

É crime de mera conduta, consumando-se no momento da ação, independentemente de qualquer resultado.

Como aponta o texto legislativo, para a incidência do tipo se exige que o local seja o interior de residência, desde que esta seja sua, ou local de trabalho, desde que seja o réu o titular ou o responsável pela empresa. Sendo o imóvel alheio a imputação correta é no artigo 14 (porte).

Embora a jurisprudência do STJ seja no sentido de dispensar a prova pericial no caso de munições para os artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, com o devido respeito à corte superior, as razões não convencem. O fato de o delito ser de mera conduta e perigo abstrato não indica a desnecessidade de prova pericial, pois o porte de arma de fogo previsto nos mesmos tipos também o é e exige. Em verdade, a prova pericial serve justamente para atestar o perigo abstrato da munição, ou seja, a possibilidade dela vir a turbar a segurança pública e a incolumidade pessoal dos cidadãos. Imaginemos a hipotética situação de alguém que faz uma escultura com uma munição de rifle, sendo o invólucro perfeitamente idêntico, mas sem propelente e com a espoleta vazia. Ora, a simples posse desse objeto é incapaz de atingir o bem jurídico previsto pela norma penal da forma prevista por ela. Ou seja, somente após a perícia é que se pode determinar se o objeto representou, de fato, perigo, ainda que abstrato.

Ficou comprovada a existência do crime e a autoria.

A existência dos crimes estão provadas pelo boletim de ocorrência de fls. 19/26, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 27/30, pelo auto de constatação de fls. 31/32, pelo exame químico toxicológico de fls. 150/154, pelo laudo pericial de fls. 155/157 que apontou "em condição(ões) de uso; em metal amarelo; dotado(s) de projétil(eis) chumbo nu coberto por tinta emborrachada preta; do tipo tronco cônico; portador(es) de marca e calibre "GFL 357 MAGNUM", para uso em armas de fogo do calibre nominal .357 MAGNUM ou compatível" e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, Leonardo Parada do Amaral, investigador de polícia, disse, em sede inquisitiva, que recebeu informações por meio da Guarda Municipal de que teriam abordado um veículo Ford/Fiesta, de cor vermelha que era suspeito da prática de uma tentativa de roubo na semana do dia 26/01/2022. Após a abordagem, entrevistaram o condutor do Ford/Fiesta vermelho e este foi conduzido até a Delegacia e ouvido sobre o seu veículo ser suspeito na prática do roubo. O condutor contou para os guardas municipais que teria recebido uma proposta de levar dois indivíduos para o local do fatos, e permanecido no local, em seu veículo. Após a ação, um dos indivíduos, pediu para deixá-lo, próximo ao local onde se realiza provas para tirar habilitação, uma rua próximo ao Auto Posto Ipiranga, na Ademar de Barros. Diante dessas informações obtidas e juntamente com os Guardas Municipais, GCM Renzo e GCM Degan, foram até a Rua João Pulz e observaram uma casa de numeral 150, que havia mesa de plástico na frente e alguns resquícios de maconha no local. Ao adentraram na residência, haja vista, a fundada suspeita e os indícios de droga no local, contataram a pessoa de Tainá, a qual disse que reside no local e que, nos fundos, estaria ficando o namorado de sua prima de nome Daniel. Os policiais adentraram o imóvel, após a autorização, e nos fundos do imóvel, localizaram certa quantidade de droga, a saber: 01 pedaço de maconha, em forma de tijolo pesando aproximadamente 327 gramas; 04 pedras de substância crack, pesando aproximadamente 15 gramas; ervas verde aparentando ser maconha, fracionada, pesando aproximadamente 128 gramas; 01 pedaço de substância escura pesando aproximadamente 18 gramas; Uma porção de pó branco pesando aproximadamente 122 gramas; uma porção de pó amarelado aparentando ser cocaína pesando aproximadamente 50 gramas; duas balanças de precisão; duas facas com resquícios de drogas; um caderno com anotações suspeitas; 133 pinos vazios; Uma munição calibre 357 Magnum, e um aparelho celular de marca

Samsung de cor azul. Tainá disse que aquele material pertencia ao namorado de sua prima de nome Daniel, bem como que não sabia da existência da droga, mas sabia que DANIEL estava traficando drogas e já fora preso por roubo. Além disso, Tainá disse que Daniel não estava na casa no momento, pois teria ido para Cosmópolis. Acrescentou que sabia onde era a residência de Daniel na cidade de Cosmópolis, e levou os Policiais até o local. Em Cosmópolis, na Rua Moacir do Amaral, n 51 fundos, BelaVista, residência de Daniel, obtiveram contato com o morador da frente, tio de Daniel, Rodinei de 59 anos, o qual disse que Daniel morava nos fundos do imóvel e autorizou que fosse feito uma vistoria no imóvel. Ali foram encontrados maconha fragmentada, pesando 42 gramas, 06 porções de pó branco aparentando ser cocaína, bem como um aparelho celular de marca Motorola cinza, pertencente a Daniel e um aparelho de celular marca Samsung de cor preta, pertencente a Higor, um aparelho celular de marca Motorola de cor rosa pertencente a Daniel, um aparelho de cor dourado de marca Samsung pertencente a Higor, um boné, R\$ 320,00 em dinheiro, 01 rolo de fita adesiva, embalagens plásticas, 01 coador e 01 tesoura com resquícios. Ato contínuo, foram informados de que Daniel e Higor estariam ali na mesma rua no cabeleireiro onde foram até aquele local e abordaram a pessoa de Daniel e Higor, sendo que com Daniel, em sua carteira, foi localizado R\$ 550,00 em dinheiro e com o Higor, foi localizado a quantia de R\$ 83,65 em dinheiro. Diante dos indícios e das evidências ambos foram conduzidos até a delegacia. A testemunha de acusação, André Renzo de Jesus, guarda municipal, disse, em fase policial, que uma viatura da Guarda Municipal teria abordado um veículo Ford/Fiesta, de cor vermelha, suspeito da prática de uma tentativa de roubo na semana do dia 26/01/2022. Após a abordagem, o condutor do Ford/Fiesta vermelho, foi entrevistado e conduzido até a Delegacia e afirmou que teria recebido uma proposta de levar dois indivíduos para o local do fatos e permanecido no local, em seu veículo. Após, um dos indivíduos, pediu para deixá-lo, próximo ao local onde se realiza provas para tirar habilitação, na rua próximo ao Auto Posto Ipiranga, na Ademar de Barros. Diante dessas informações obtidas, e juntamente com os Guardas Municipais, GCM Degan e o Investigador de Polícia Leonardo, foram até a Rua João Pulz, e observaram uma casa de numeral 150, que havia uma mesa de plástico na frente e visualizaram alguns resquícios de maconha no local. Tendo em vista a fundada suspeita e os indícios de droga, contataram a pessoa de Tainá, a qual disse que reside no local e que, nos fundos, estaria ficando o namorado de sua prima de nome Daniel. Os policiais adentraram o imóvel, após a autorização, e nos fundos do imóvel, localizaram certa quantidade de droga, a saber: 01 pedaço de maconha, em forma de tijolo pesando aproximadamente 327 gramas; 04 pedras de substância crack, pesando aproximadamente 15 gramas; ervas verde aparentando ser maconha, fracionada, pesando aproximadamente 128 gramas; 01 pedaço de substância escura pesando aproximadamente 18 gramas; Uma porção de pó branco pesando aproximadamente 122 gramas; uma porção de pó amarelado aparentando ser cocaína pesando aproximadamente 50 gramas; duas balanças de precisão; duas facas com resquícios de drogas; um caderno com anotações suspeitas; 133 pinos vazios; Uma munição calibre 357 Magnum, e um aparelho celular de marca Samsung de cor azul. Tainá disse que aquele material pertencia ao namorado de sua prima de nome Daniel, bem como que não sabia da existência da droga, mas sabia que DANIEL estava traficando drogas e já fora preso por roubo. Além disso, Tainá disse que Daniel não estava na casa no momento, pois teria ido para Cosmópolis. Acrescentou que sabia onde era a residência de Daniel na cidade de Cosmópolis, e levou os Policiais até o local. Em Cosmópolis, na Rua Moacir do Amaral, n 51 fundos, BelaVista, residência de Daniel, obtiveram contato com o morador da frente, tio de Daniel, Rodinei de 59 anos, o qual disse que Daniel morava nos fundos do imóvel e autorizou que fosse feito uma vistoria no imóvel. Ali foram encontrados maconha fragmentada, pesando 42 gramas, 06 porções de pó branco aparentando ser cocaína, bem como um aparelho celular de marca Motorola cinza, pertencente a Daniel e um aparelho de celular marca Samsung de cor preta, pertencente a Higor, um aparelho celular de marca Motorola de cor rosa pertencente a Daniel, um aparelho de cor dourado de marca Samsung pertencente a Higor, um boné, R\$ 320,00 em dinheiro, 01 rolo de fita adesiva, embalagens plásticas, 01 coador e 01 tesoura com resquícios. Ato

continuo, foram informados de que Daniel e Higor estariam ali na mesma rua no cabeleireiro onde foram até aquele local e abordaram a pessoa de Daniel e Higor, sendo que com Daniel, em sua carteira, foi localizado R\$ 550,00 em dinheiro e com o Higor, foi localizado a quantia de R\$ 83,65 em dinheiro. Diante dos indícios e das evidências ambos foram conduzidos até a delegacia.

A testemunha de acusação, Alexandre Albino Degan, guarda municipal, prestou suas declarações no mesmo sentido do seu parceiro.

DANIEL ROBERTO DA SILVA ZERBINATTI, em seu interrogatório na fase policial, manteve-se em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse, todavia, que em Cosmópolis só havia 25g de maconha. Os demais entorpecentes e acessórios estavam todos armazenados na residência de Artur Nogueira.

Independentemente de o acusado ter confessado os fatos, os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, presentes o réu e seu defensor, tiveram estas plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada. STJ, HC 115516/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 03/02/2009.

"O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova". STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016.

TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso. TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 20.08.2013.

"No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais militares, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os

policiais não agiram escorреitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante". TJSP, Apelação n. 0068618-51.2017.8.26.0050, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 08.08.2018.

Quanto à possibilidade de desclassificação para o delito previsto no topo do art. 28 da Lei 11.343/06, lembro que o §2º deste dispositivo diz que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso, a diversidade e a quantidade de drogas apreendidas, além do passado do réu ligado à criminalidade indicam que a posse não era para o mero uso, mas tinha finalidade comercial.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Todavia, ainda que a apreensão dos entorpecentes tenha se dado em locais diversos, verifico a existência de crime único. Nesse sentido:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉUS QUE TRANSPORTAVAM E TINHAM EM DEPÓSITO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, DESTINADAS AO COMÉRCIO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO - APREENSÃO DE TÓXICOS EM LOCAIS DIVERSOS - CONTINUIDADE DELITIVA - AFASTAMENTO - NECESSIDADE. Sendo o art. 33 da Lei de Drogas tipo misto alternativo composto de dezoito verbos, se o agente praticar quaisquer das condutas ali descritas, configurado estará um único crime, mormente quando as apreensões dos entorpecentes foram feitas no mesmo contexto e lavradas no mesmo flagrante. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E DE DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS E APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APR: 00052727820148260294 SP 0005272-78.2014.8.26.0294, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 24/11/2016, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/11/2016)

Além disso, com base no auto de apreensão e exibição, bem como o laudo pericial que atestou a efetividade da munição apreendida, restou configurado, assim, o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cujo preceito secundário prevê pena de "detenção, de (1) um a (3) três anos, e multa".

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que o réu possui maus antecedentes que serão valorados na segunda fase da dosimetria penal. Ademais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., RESp. 1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

Portanto, em referência ao critério da natureza da droga, por constarem da Lista F do Anexo I (substâncias de uso proscrito, ou seja, proibidas sob quaisquer circunstâncias ou concentrações pela natureza intrinsecamente nociva que possuem), merecem valoração nesta fase a maconha e cocaína, sendo que esta em especial (e em maior grau o crack, seu derivado), por causar severa dependência em seus usuários. O STJ, responsável pela uniformização da aplicação do direito infraconstitucional, tem entendido como razoável o aumento de um décimo na pena-base para quantias em torno de 100g de cocaína.

"No caso, observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento o art. 42 da Lei de Drogas, elevou a pena-base em 1 ano, em razão da aferição desfavorável da quantidade e da natureza da droga (120 g de cocaína). Tendo sido indicados elementos válidos para a majoração da reprimenda básica, uma vez que significativo o quantum e altamente nociva a substâncias apreendida, não se identifica a alegada contrariedade do art. 59 do CP, sobretudo quando tais circunstâncias foram

elencadas legalmente como preponderantes, e as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão."STJ, HC 431541/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018.

Desta forma, a reprimenda pela maconha deve ser feita em patamar inferior e a valoração negativa pelo crack em patamar superior.

Assim, conjugando as drogas apreendidas com as quantidades encontradas, aplico um acréscimo de 1/6 (um sexto) nesta fase, resultando em 5 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa pelo tráfico de drogas.

Mantenho a pena por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido no mínimo legal, 1 (um) ano de detenção e 10 dias-multa.

Segunda etapa. Presente a agravante da reincidência (certidão de objeto e pé de fls. 208/209) e a atenuante da confissão, realizo a compensação e fixo as penas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (seiscentos e oitenta) dias-multa pelo tráfico de drogas e 1 (um) ano de detenção e 10 (dias) dias-multa pela posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Inviável a aplicação do redutor, tendo em vista ser o réu reincidente.

Fixo, de forma definitiva, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pelo tráfico de drogas e 1 (um) ano de detenção e 10 (dias) dias-multa pela posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Inviável a aplicação do concurso material dos crimes, uma vez que o delito de tráfico é apenado com reclusão e o crime de porte ilegal, com detenção.

Regime inicial de cumprimento. Sendo o réu reincidente, em interpretação "contrario sensu" das alíneas "b" e "c" do §2º do art. 33 do Código Penal, o regime é, necessariamente, o fechado para o crime de tráfico de drogas e semiaberto para o crime de porte ilegal. Além disso, a reincidência constitui valoração gravemente negativa dos antecedentes do réu, que persistiu na vida do crime mesmo após sancionado severamente e, desta forma, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal também merece o regime inicial mais gravoso. A reincidência também impede a aplicação do redutor, a suspensão da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional. Neste sentido:

"A agravante obsta o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e, juntamente com a pena corporal, obrigava a fixação do regime inicial fechado e impedia a substituição por restritivas de direitos." TJSP, Apelação n. 0000411-

36.2016.8.26.0599, Rel. Des. Vico Manhães, j. 23.05.2018.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR DANIEL ROBERTO DA SILVA ZERBINATTI à pena de reclusão, pelo prazo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06, e à pena de detenção, pelo prazo de 1 (um) ano e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Ante a presença de circunstâncias judiciais negativas e reincidência específica do réu, mantenho a prisão preventiva, agora verificada em cognição exauriente a conduta reiterada do acusado na atividade delitativa.

Condeno o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Artur Nogueira, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA